TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1932/24

IMPEDIMENTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Declarar fundado el impedimento por haber sido apoderado, contraparte o asesor de alguna de las partes

IMPEDIMENTOS-Mecanismo procedimental dirigido a la protección de los principios esenciales de la administración de justicia

REVISION DE ACCIONES DE TUTELA-Causales de impedimento serán las previstas en el Código de Procedimiento Penal

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1932 DE 2024

Referencia: Expediente T-8.996.071

Asunto: Acción de tutela presentada por Camilo Solano Niño contra la Sala Plena de la Corte Constitucional

Conjuez ponente: Carlos Alberto Ateorthúa Ríos

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

I. ANTECEDENTES

1. El ciudadano Daniel Camilo Solano Niño presentó acción de Tutela contra la Corte Constitucional, con el propósito de que se ordene retirar el crucifijo ubicado en el recinto de la Sala Plena, pues, en su criterio, se trata de un símbolo religioso, de manera que su presencia es incompatible con el pluralismo, la laicidad y la neutralidad del Estado.

2. Radicada la acción, el 15 de mayo de 2023, el expediente de tutela T-8.996.071 fue asignado al despacho de la magistrada Diana Fajardo, mediante Auto de la Sala de Selección de Tutelas número Once. La Sala Plena asumió conocimiento el 15 de agosto de 2023, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. Sin embargo, los magistrados que la integran consideraron que están impedidos para conocer y decidir en sede judicial sobre el problema jurídico planteado.

3. De manera conjunta los honorables magistrados integrantes de la Sala Plena de la Corte Constitucional: José Fernando Reyes Cuartas, Natalia Ángel Cabo, Juan Carlos Cortés González, Diana Fajardo Rivera, Vladimir Fernández Andrade, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Antonio José Lizarazo Ocampo, Paola Andrea Meneses Mosquera y Cristina Pardo Schlesinger, manifestaron que se encuentran impedidos para tramitar y decidir la Tutela presentada en el proceso de la referencia.

4. Como antecedente, en la manifestación conjunta de impedimento se indicó que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo, al estimar que el crucifijo tiene un valor histórico y cultural, y que el pluralismo reconocido en la Constitución no favorece una visión atea de la religión. Dicha decisión fue confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con base en argumentos similares.

5. Además, expresaron que esta Corporación, en jurisprudencia constante, ha manifestado que la imparcialidad judicial hace parte de las garantías del derecho fundamental al debido proceso, previsto en el artículo 29 superior. En desarrollo de este principio, el Legislador ha definido las hipótesis específicas que deben ser advertidas por parte del funcionario judicial en aras de un adecuado y correcto ejercicio del servicio público de administración de justicia y, al mismo tiempo, en

defensa de los derechos constitucionales.

6. Sobre las causales de recusación e impedimento señalaron que sus causales son taxativas, de acuerdo con la definición legal; y deben ser leídas de manera literal y restrictiva, para preservar, en la mayor medida posible, la integración constante de los tribunales y cortes. De conformidad con el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 99 del Reglamento Interno de esa Corporación, en materia de tutela son aplicables aquellas causales previstas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal4.

7. Se señaló que el numeral 4º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal establece que está impedido para conocer de un proceso el funcionario judicial que haya sido contraparte dentro de un proceso.

8. En la manifestación conjunta de declaración del impedimento se resaltó que, en este caso, la acción de tutela se dirige contra la Sala Plena de la Corte Constitucional, de la cual hacen parte los magistrados que expresaron estar impedidos. Así, en el escrito de tutela se cuestiona la conducta de haber permitido la permanencia del crucifijo en dicho recinto, o la omisión de retirarlo ante la solicitud elevada por el actor, a través del derecho de petición. Ambas son conductas atrribuidas a la Sala Plena, en especial, si se tiene en cuenta que el crucifijo llegó al recinto a raíz de una discusión sostenida en sesión de Sala Plena, como consta en Acta de 7 de julio de 1999.

9. Expresaron los magistrados en su manifestación de impedimento que, si bien la composición de la Sala cambió desde entonces, consideran que, desde la perspectiva de la omisión, y tras la existencia de dos acciones de tutela en las cuales la institución ha remitido respuestas a los jueces competentes, intervenir en esta deliberación y decisión implicaría asumir la condición de juez y parte dentro de la controversia y que la ciudadanía podría considerar válidamente afectada la imparcialidad del juez.

10. En adición a las razones expuestas, la H. Magistrada Cristina Pardo Schlesinger también considera que está impedida para pronunciarse sobre el expediente de la referencia porque, en su calidad de presidenta de la Corte, contestó la acción de tutela el 5 de mayo de 2022; y le delegó funciones a la abogada sustanciadora de la Sala Plena para que respondiera la solicitud presentada por el accionante el 8 de abril de 2022, donde reiteraba su petición de retirar el crucifijo del recinto donde tienen lugar nuestras deliberaciones.

11. Finalmente expresaron los H. Magistrados en su escrito que por "*las anteriores*

consideraciones, plasmamos por escrito el impedimento conjunto presentado verbalmente en la sesión de la Sala Plena del día de ayer, 2 de octubre de 2024, con el propósito de preservar las garantías de transparencia, imparcialidad e independencia; la consistencia en nuestras actuaciones y, en especial, la legitimidad y validez de las providencias de esta Corte. El fin último de esta declaración consiste en defender la majestad de la justicia, sin tacha alguna de dependencia o parcialidad en los asuntos que deben resolverse."

II. DESIGNACIÓN DE CONJUECES Y PONENTE.

12. Una vez presentada la manifestación de impedimento conjunto de la totalidad de los integrantes de la Sala Plena de la Corte Constitucional, se procedió al sorteo para la designación de Sala Plena de Conjueces, la cual quedó integrada por los doctores: José Alpiniano García Muñoz; Carlos Alberto Atehortúa Ríos (Ponente); Jorge Gaitán Pardo; Mónica Cifuentes Osorio: Jaime Humberto Tobar Ordoñez, Luis Hernando Parra Nieto, Ruth Stella Correa Palacio, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Mauricio Fajardo Gómez, de los cuales se designó como ponente a Carlos Alberto Atehortúa Ríos.

III. PROBLEMA JURÍDICO.

13. Debe tenerse en cuenta que en esta oportunidad la Sala de Conjueces se limitará a pronunciarse sobre la existencia o no de impedimento por parte de los integrantes de la Sala Plena de la Corte Constitucional, para decidir en un proceso en el cual ostentarían la condición de juez y parte, pues a la vez que les corresponde adelantar las actuaciones propias de las acciones de Tutela, suministrar al menos parte de la información con la cual se adoptará la decisión final del dentro del proceso y cumplir la decisión que se adopte, estaría tomando decisiones relevantes sobre la Tutela presentada.

IV. PROCEDENCIA DE LA MANIFESTACIÓN DE DECLARATORIA DEL IMPEDIMENTO.

14. De conformidad con lo previsto en los artículos 39 del Decreto Ley 2591[1] de 1991 y 99 del Reglamento de la Corte Constitucional[2], la Sala Plena de la Corte Constitucional es la Autoridad competente para conocer del impedimento por ella propuesto, integrada en esta oportunidad por la Sala de Conjueces.

V. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES EN TUTELA EN ESTA

CORPORACIÓN.

15. Los impedimentos y recusaciones tienen como fundamento constitucional garantizar la neutralidad, independencia e imparcialidad en la función constitucional de impartir justicia, en este sentido en el Auto A-740-24, esta corporación expresó lo siguiente:

*"**El impedimento como instrumento procesal necesario para garantizar la independencia e imparcialidad del juez***

5. La regulación sobre los impedimentos en el trámite de acciones de tutela se encuentra en el artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que los jueces tienen en el deber de declararse impedidos para conocer y fallar un caso siempre que en ellos "[…] concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal." Este mandato, a su turno, ha sido reproducido en el artículo 99 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, el cual establece el procedimiento a seguir en caso de que el impedimento sea presentado por un magistrado de la Corte Constitucional. Cuando así ocurre, el impedimento será conocido por "el resto de los Magistrados de las Salas de Selección, Revisión o Plena, según el caso", con observancia del trámite "contemplado en el artículo 27 del Decreto 2067 de 1991."

6. Esta Corte ha considerado de manera reiterada y pacífica que el régimen de impedimentos y recusaciones permite la materialización del principio de imparcialidad del juez, el cual constituye un pilar esencial de la administración de justicia. A su vez, ha sostenido que el hecho de que cualquier persona pueda acudir ante una autoridad judicial para que le sea resuelta su controversia con total imparcialidad, materializa o concreta las garantías previstas en el derecho fundamental al debido proceso.

7. De acuerdo con ello, el principio de imparcialidad exige a los jueces y magistrados que su actuación esté encaminada a administrar justicia con apego a las reglas de derecho pertinentes para la solución de los casos sometidos a su consideración. De esta manera, siempre que el funcionario advierta la existencia de motivos fundados que comprometan la imparcialidad de su juicio en dicha labor, tiene el deber de apartarse de la deliberación y decisión del asunto específico respecto del cual esto ocurre. Lo anterior, con el fin de garantizar que el fallo se profiera con observancia del principio de estricta legalidad.

8. Por otra parte, la jurisprudencia también ha reconocido que, en todo caso, la facultad de manifestar impedimentos no es "omnímoda, arbitraria o

caprichosa", pues la misma se funda en causales taxativas, que deben ser interpretadas de manera restringida, con la finalidad de evitar limitaciones excesivas y desproporcionadas al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. De lo anterior se sigue la necesidad de analizar la fundamentación y argumentación de los impedimentos con particular rigurosidad y exigencia, para determinar si estos se encuentran fundados."

16. La cita anterior permite deducir la importancia de los impedimentos de jueces y magistrados, como parte integrante del debido proceso, en el ejercicio de la función constitucional de impartir justicia.

1. La causal invocada y su procedencia. Aplicación objetiva por tratarse del mismo proceso.

17. En este caso la causal de impedimento invocada por la sala plena de esta Corte toma como fundamento lo estableció en el numeral 4º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en el cual se preceptúa:

"**ARTÍCULO 56.** ***Causales de impedimento.*** Son causales de impedimento:

"...

"4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.

18. A pesar de que en principio la acción de Tutela es instaurada contra un centro de imputación jurídica diferente de las personas naturales que lo integran, como es el caso de la Corte Constitucional y los magistrados que solicitan se acepte su manifestación de impedimento, la realidad es que en este caso concreto ese centro de imputación colectivo solo se expresa a través de las personas naturales que hacen parte de él, sin que sea separables las acciones del uno y del otro. Esto es la H. Corte Constitucional actúa a través de sus miembros y por ello el régimen de impedimentos de la Corporación, así como la responsabilidad por las decisiones en este caso se predica de sus integrantes.

Se afirma lo anterior, por cuanto es a los H. Magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional a quienes de manera individual o colectiva les corresponde adelantar la actuación procesal correspondiente en el trámite de la acción de Tutela instaurada,

presentar total o parcialmente la información requerida y especialmente dar cumplimiento a la decisión final que se emita en el trámite del proceso y aún si es del caso impugnar la decisión que se adopte, lo que evidencia que en este caso se estaría actuando como juez y parte en el proceso, contrariando de manera evidente la garantía constitucional del debido proceso a que tiene derecho no solo el accionante, sino todos los habitantes del territorio nacional, que están en la obligación de acatar la decisión que se adopte, pues, bien en principio la Tutela solo produce efectos interpartes en casos como el presente no solo la ratio decidendi de la providencia, sino la decisión misma será oponibles con efectos erga omnes.

En relación con el contenido y alcance de la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, la H. Corte Constitucional en el Auto 1009-21, expresó lo siguiente:

> ***2.Sobre la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del Artículo 56 del Código de Procedimiento Penal***
>
> *8. Ahora bien, la Ley 906 de 2004, a la cual hace remisión expresa el Reglamento Interno de la Corte Constitucional, establece de forma taxativa las causales de impedimento aplicables a los procesos de revisión de tutela. Uno de los eventos consagrados en el ordenamiento procesal penal corresponde al invocado, en el marco de este trámite constitucional, por el magistrado Alejandro Linares Cantillo, es decir, el contenido en el numeral 4 del Artículo 56 de ese cuerpo normativo, según el cual constituye una causal "[q]ue el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso." (Énfasis añadido).*
>
> *9. La jurisprudencia de esta Corporación, así como la desarrollada por otros Tribunales de cierre del ordenamiento jurídico, ha precisado que la enunciación normativa de esa causal contiene tres supuestos específicos de impedimento para el funcionario judicial, en concreto: (i) haber sido apoderado de alguna de las partes; (ii)* ***ser o haber sido su contraparte****; o (iii) haber manifestado su opinión o dado consejo, "sobre el asunto materia del proceso."**[3]** Bajo ese contexto, la Sala se concentrará principalmente en el primer supuesto, en razón de los hechos expuestos por el doctor Alejandro Linares Cantillo. (Resaltado fuera del texto)*

19. En el contexto de esta providencia, la causal sería "ser o haber sido contraparte" y esa condición se presenta bajo la modalidad de "ser contraparte", pues con independencia de la posición asumida por los H. magistrados que integran la Sala Plena

de la Corte Constitucional, el accionante reprocha lo que para él constituye una conducta omisiva que es actual por parte de los accionados.

20. La acción de tutela en este caso es contra "la sala plena de la Corte Constitucional" organismo de carácter colegiado, que se expresa a través de la actividad que desarrollan sus integrantes y que a través de ellos debe concurrir al trámite del proceso que se adelante y en especial deberán acoger o cumplir la decisión judicial que se adopte dentro del proceso instaurado.

21. Ahora bien, es importante resaltar que, en este caso, la condición de juez y parte se tiene en un mismo proceso, lo que permite que el análisis de la aplicación de la causal sea objetivo, sin que se requiera un análisis de las condiciones subjetivas en las que actúa cada uno de los magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional. En relación con la forma como debe aplicarse la causal de impedimento en estos casos, esta Corporación, en decisión de sala plena, contenida en la sentencia C-496-16 expresó lo siguiente:

> *"De hecho, aunque el Código de Procedimiento Penal, como lo señalan los actores, contempla expresamente esta causal de impedimento y recusación, lo cual parecería indicar que es de naturaleza objetiva, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en realidad no lo es sino cuando esa situación se presenta en el mismo proceso en el que el juez está llamado a ejercer funciones jurisdiccionales. En contraste, cuando el juez o conjuez ha sido contraparte de las partes o de sus apoderados en un proceso diferente al que está en curso, la jurisprudencia exige demostrar, además de esa circunstancia, una afectación concreta a la imparcialidad judicial. Es decir, no basta con probar un hecho objetivo, sino que debe acreditarse una duda razonable de afectación subjetiva de quien encarna la autoridad jurisdiccional. En efecto, al menos desde el auto del 4 de septiembre de 1998, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostiene que la causal de impedimento y recusación contra el juez por ser o haber sido contraparte de las partes o de sus apoderados "resulta atendible cuando en la misma actuación judicial se presente la circunstancia de que el fallador y uno de los sujetos procesales hayan sido contrapartes. Pero, en tratándose de procesos diferentes, es menester que el funcionario que se declara impedido demuestre que, conforme a las circunstancias que cobijan la relación jurídico-procesal, su imparcialidad y objetividad se van a ver afectadas".**[4]** Esta posición se ha reiterado en múltiples ocasiones, y por eso por ejemplo en el auto del 9 de mayo de 2007 de la misma Corporación se dijo al respecto:*
>
> *"…vale reiterar que la jurisprudencia de la Corte ha sido pacífica en torno al concepto de contraparte como motivo excusante para conocer del proceso, pues su alcance implica una doble perspectiva, a saber:*

"a) Que dicha condición se predique en el mismo proceso, es decir, que el juez que debe resolver el asunto tenga al mismo tiempo la condición de adversario frente a cualquiera de los sujetos procesales.

*"b) Que esa condición de adversario se presente en otro proceso, evento en el cual 'deberán examinarse las específicas circunstancias temporales y morales que caracterizan la relación jurídico procesal, y determinar así la incidencia concreta que tal calidad pueda tener en la objetividad e imparcialidad del funcionario".**[5]***

Como se observa, en realidad, ni siquiera en el proceso regulado por el Código de Procedimiento Penal, en el que se consagra expresamente la causal de recusación e impedimento para jueces y conjueces por ser o haber sido contrapartes de las partes o sus apoderados, esa sola circunstancia es considerada como indicador suficiente de falta de imparcialidad judicial. No advierte la Sala Plena de esta Corporación razón alguna para dudar fundadamente de la imparcialidad de un juez civil o contencioso administrativo, solo por el hecho de haber sido contraparte de las partes o de sus apoderados en procesos diferentes al que está en curso, y con independencia de las circunstancias en que se hubiese desarrollado. La Corte no está entonces ante un caso en el cual la omisión cuestionada, entendida en sentido estricto, carezca de justificación suficiente. Tal omisión se justifica suficientemente en que esa circunstancia objetiva no es en cuanto tal un elemento que baste por sí mismo para demostrar, ausentes otras condiciones, falta de imparcialidad en el juez o conjuez de la causa.

***3.* Procedencia de la ausal para el caso concreto**

22. Se reitera que el texto literal de la causal de impedimento invocada por los magistrados que integran la Sala Plena, que está consagrada en el numeral 4 del artículo 56 del código de Procedimiento Penal es el siguiente: "Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, ***o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos***, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso." (Resaltado fuera del texto), circunstancia que esta sala de Conjueces considera que se presenta en el caso concreto, con la connotación especial de que la condición de "juez y contraparte", se presenta en un mismo proceso y en consecuencia aceptará la manifestación presentada.

23. A la anterior conclusión se llega de la lectura simple del texto transcrito pues en

este caso, los magistrados que integran la Sala Plena de la Corte tienen la condición jurídica de "contraparte del accionante", pues en su criterio la sola omisión que han tenido al no adoptar medidas como la solicitada en la acción de Tutela ocasiona que se adelante la acción judicial en su contra.

24. Así pues, en este caso se reúnen las condiciones estructurales para el reconocimiento del impedimento, pues de un lado, existe la causal objetiva que es la prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, y se dan las condiciones subjetivas de los magistrados que integran la Sala Plena de Corte Constitucional, al deber actuar como contraparte en la acción de Tutela instaurada.

25. Finalmente considera la sala de conjueces, que estando todos los magistrados que integran la Sala Plena de la H. Corte Constitucional impedidos para intervenir en el caso objeto de este pronunciamiento, no es necesario hacer un análisis adicional en relación con las motivaciones adicionales expresadas por la H. Magistrada Cristina Pardo Schlesinger.

-

-

VI. DECISIÓN

-

RESUELVE:

-

Primero. DECLARAR que el impedimento presentado por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Natalia Ángel Cabo, Juan Carlos Cortés González, Diana Fajardo Rivera, Vladimir Fernández Andrade, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Antonio José Lizarazo Ocampo, Paola Andrea Meneses Mosquera y Cristina Pardo Schlesinger en proceso contenido el en el expediente T-8.996.071 se encuentra fundado. En consecuencia, se **ACEPTA** el impedimento formulado y se les declara separados del proceso.

-

Segundo. DISPONER que en firme esta decisión, se proceda al sorteo de conjueces que asumirán el conocimiento del proceso en reemplazo de los magistrados a quienes se aceptó el impedimento.

Comuníquese y cúmplase.

-

-

-

-

-

-

CARLOS ALBERTO ATEHORTUA RIOS

Conjuez

-

-

-

LUIS HERNANDO PARRA NIETO

Conjuez

-

-

-

JAIME HUMBERTO TOBAR ORDÓÑEZ

Conjuez

Ausente con excusa

-

-

-

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Conjuez

-

-

-

JORGE GAITAN PARDO

Conjuez

-

-

-

JOSE ALPINIANO GARCIA MUÑOZ

Conjuez

Con aclaración de voto

-

-

-

MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

Conjuez

-

-

-

MONICA CIFUENTES OSORIO

Conjuez

-

-

-

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Conjuez

-

-

-

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

-

-

-

-

-

-

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONJUEZ

JOSÉ ALPINIANO GARCIA MUÑOZ

AL AUTO QUE DECIDE SOBRE EL IMPEDIMENTO CONJUNTO PRESENTADO POR LA SALA PLENA

-

-

Referencia: expediente T-8.996.071

-

Asunto: Auto 1932 de 2024. Acción de Tutela instaurada por Daniel Camilo Solano Niño contra la Corte Constitucional

-

Conjuez ponente: Carlos Alberto Atehortúa Ríos

-

-

Con todo respeto me permito hacer las siguientes aclaraciones de mi voto al auto que decide sobre los impedimentos presentados en el expediente T-8.996.071.

-

1. Un problema jurídico adicional

-

El proyecto de auto presentado aborda la cuestión referente al impedimento argumentado por los magistrados de la Corte Constitucional y lo resuelve en la forma que corresponde. No obstante, existe un problema adicional que no trata: ¿desde qué momento afecta al trámite de la tutela de autos, el impedimento esgrimido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, y de manera especial, por los Magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera y José Fernando Reyes Cuartas?

-

2. Consideraciones generales

-

Ciertamente, como bien concluyen los señores magistrados, intervenir en la "deliberación y decisión [de la tutela de autos] implicaría asumir la condición de juez y parte dentro de la controversia". El maestro Carnelutti la identifica como la "hipótesis más extrema (…), la de que el juez fuese una de las partes; el principio *nemo iudex in causa propia* es, en verdad, un axioma. Claro que semejante hipótesis es muy rara[6]", concluye. Así pues, según el autor italiano, estamos ante una causal de impedimento muy especial. Por ello estimo necesario hacer unas consideraciones adicionales.

-

Desde el 15 de mayo de 2023, cuando la Sala de Selección de Tutelas "conformada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas", *seleccionó para revisión* la tutela instaurada por el ciudadano Daniel Camilo Solano Niño, tanto los doctores Meneses y Reyes, como los otros magistrados de la Corte Constitucional, *hacían parte de la Sala Plena contra la cual se dirigía dicha tutela. También desde aquella fecha, el señor Solano Niño ya había interpuesto acción de tutela* contra la Corte Constitucional. Dicho brevemente, para la fecha de la selección de la tutela ya existía el impedimento argüido por los señores magistrados.

-

Importa dejar claro que los impedimentos en los procesos ante la Corte Constitucional pueden existir aún desde el momento de "resolver sobre la selección de un caso". Es lo que establece el artículo 55 inciso 7º del Acuerdo 02 de 2015 del Reglamento de la Corte Constitucional. El Derecho Comparado concuerda y ayuda a entender los alcances de esta disposición nacional. Las normas vigentes en Estados Unidos de América son orientadoras.

-

El artículo 455 del título 28 del *U.S. Code,* al regular nuestros impedimentos y recusaciones con el título de *Disqualification of justice, judge, or magistrate judge,* tiene establecido, en el literal d, que la causal de impedimento afecta la etapa del *pretrial.* Una sana hermenéutica permite ver que la *selección de un caso* de tutela por la Corte Constitucional, encuadra dentro de esta etapa. Una sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos aplicó aquella disposición, explicando, además, su implicación fundamental: en *United States of America, Plaintiff-appellee, v. David Arnold Feldman*, recogido en 983 F.2d 144 (9th Cir. 1992), dijo que cuando la causal de apartamiento del juez "es procedente, no está a discreción del juez limitarla a cierta materia o sólo a ciertos asuntos y no a otros (…), debe abarcar (…) la entera 'etapa del litigio'".

-

Entonces, si la causal de impedimento argüida por los señores magistrados *ya existía desde el 15 de mayo de 2023, cuando la Sala de Selección de Tutelas* número once de la Corte Constitucional seleccionó la tutela de autos; y *no está a discreción del juez limitar*

los alcances de tal impedimento, la selección de dicha tutela no podía hacerse. Estamos ante una decisión de selección nula.

-

Adicionalmente, si el impedimento *debe abarcar la entera etapa del litigio y no está a discreción del juez limitar sus alcances*, no procede que un juez de una sala en quien concurra un impedimento, resuelva sobre idéntico impedimento en otro juez miembro de idéntica sala. En el caso de autos, la decisión sobre el impedimento y sus alcances sólo puede corresponder a esta Sala de Conjueces. Es la interpretación que debe darse, para este caso, al artículo 99 del Reglamento de la Corte Constitucional que atribuye al "resto de los Magistrados de las Salas de Selección, Revisión o Plena", *conocer* de los impedimentos en que concurran los magistrados. Esta interpretación restrictiva se justifica aún más, porque estamos ante el impedimento que tipifica la *hipótesis más extrema: el juez es una de las partes,* según dice Carnelutti citado arriba.

-

El reglamento de la Corte Constitucional regula las nulidades en el artículo 106. El texto obliga a inferir que se trata de nulidades solicitadas por las partes. En el primer inciso exige "solicitud de nulidad", aunque en el segundo inciso (literal a) refiere *nulidad invocada*. El asunto resulta confirmado en el auto A-3008/23 de la Corte Constitucional cuando se refiere a los requisitos formales para estudiar a fondo la nulidad: *deben concurrir*, dice, *oportunidad*, *carga argumentativa* y, el que nos interesa para este caso "*legitimación*, según el cual puede ser presentado por las partes o quiénes hayan participado en el trámite, así como por un tercero afectado con las órdenes proferidas". No parece, entonces, que las normas que regulan los procedimientos ante la Corte Constitucional indiquen el trámite a seguir en casos como el que nos ocupa (nulidad de oficio). ¿Qué hacer?

-

En primer lugar, la nulidad ocurrida reúne el requisito del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, para el que solamente procede en los procesos seguidos ante la Corte Constitucional *cuando tipifique una clara violación al debido proceso*. Ocurre en el caso de autos: intervenir en la "deliberación y decisión [de la tutela de autos] implicaría asumir la condición de juez y parte dentro de la controversia", concluyen los señores Magistrados. Es la *hipótesis más extrema que contraría una verdad axiomática del proceso* judicial, asegura uno de los más connotados doctrinantes de todos los tiempos. Se trata, entonces, de una violación al debido proceso "cualificada, esto es, ostensible, probada, significativa y trascendental", según lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el auto 149-2018.

-

Ahora bien, al regular los impedimentos de los magistrados en el artículo 99, el Reglamento de la Corte remite al Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, nada dice este estatuto acerca del procedimiento para la nulidad no pedida por una parte (de oficio), como la que nos ocupa en este caso. No obstante, según el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, *para* "la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de

tutela (…) se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso". Fue esto lo que hizo la Corte Constitucional en el auto 159/18. De ahí que resulte aplicable, al caso que nos ocupa, el artículo 132 del Código General del Proceso:

-

"Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso".

-

No es algo nuevo. En el auto A-1067/23 la Corte Constitucional reiteró su competencia para declarar la nulidad de sus providencias "no solo a solicitud de una parte, de un tercero (…), sino también de oficio o a instancias de la propia Corporación. Así lo ha admitido la Corte Constitucional, al menos, desde el auto 050 de 2000, mediante el cual la Sala Plena, de oficio, anuló la sentencia T-157 del 22 de febrero de 2000, proferida por la Sala Quinta de Revisión".

-

3. Una consideración específica

-

En el numeral 6 del acta de la Sala de Selección en la que los magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera y José Fernando Reyes Cuartas seleccionaron la tutela de autos dejaron sentado que:

-

"Durante la sesión, Juan Sebastián Vega, procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales, realizó una declaración de transparencia. Expuso que también solicitó retirar el crucifijo objeto de la discusión cuando era funcionario de la Corte Constitucional. De tal suerte, los magistrados que conforman la Sala señalaron que no se configuraría impedimento alguno, en tanto la participación de la Procuraduría en la audiencia de selección pretende 'verificar la corrección y la ortodoxia del procedimiento de selección', sin hacer consideraciones de fondo en relación con los asuntos objeto de eventual selección".

-

Estimo que compete a esta Sala Plena de Conjueces apartarse respetuosamente del anterior juicio. Haré explícitas las razones que ya están implícitas en las consideraciones anteriores:

-

3.1. Son hechos indisputados que, desde el 15 de mayo de 2023, cuando la Sala de Selección de Tutelas seleccionó la tutela de autos, los magistrados de la Corte Constitucional, especialmente los doctores Paola Andrea Meneses Mosquera y José Fernando Reyes Cuartas ya *hacen parte de la Sala Plena contra la cual se dirigía dicha tutela.* También desde aquella fecha, *el señor Solano Niño ya había interpuesto acción de tutela* contra la Corte Constitucional. La mera "participación de la Procuraduría en la audiencia de selección" no tiene poder para hacer desaparecer estos hechos constitutivos

del impedimento. Reitero, desde la sala de selección de la tutela de autos, ya existía la causal de impedimento argumentada por los señores magistrados. No es posible afirmar que "no se configuraría impedimento alguno".

-

3.2. De conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Corte Constitucional, cuya interpretación argumenté antes, corresponde al "resto de los Magistrados de las Salas de Selección, Revisión o Plena", *conocer* de los impedimentos en que concurran los magistrados. En tal virtud, el juicio o participación de la Procuraduría en la audiencia de selección de la tutela de autos, nada puede sentenciar acerca de la existencia o no de impedimentos. A lo sumo, es un concepto que el juez de instancia considerará al momento de resolver.

-

4. La decisión

-

Estimo, entonces, que la decisión que debía tomarse por la Sala Plena de Conjueces es la contenida en el auto, adicionado con un aparte en el que declare que

-

La causal de impedimento esgrimida por los señores magistrados operaba el 15 de mayo de 2023, cuando la Sala de Selección de Tutelas número once, de la Corte Constitucional, "conformada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas", resolvió *seleccionar para revisión* la tutela instaurada por el ciudadano Daniel Camilo Solano Niño, "identificada con el radicado T-8.996.071".

-

Como consecuencia de lo anterior, se decreta la nulidad de lo actuado en el trámite de revisión de tutela T-8.996.071, presentada por el ciudadano Daniel Camilo Solano Niño, desde la Sala de Selección de Tutelas número once, de la Corte Constitucional, realizada el 15 de mayo de 2023 por los magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera y José Fernando Reyes Cuartas.

-

Con todo respeto,

-

-

-

JOSE ALPINIANO GARCIA MUÑOZ

Conjuez

---

[1] Sobre los impedimentos en acción de Tutela el artículo 35 del Decreto 2591 establece:

-

ARTICULO 39.-Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso.

-

[2] El artículo 99 del Reglamento de la Corte Constitucional establece:

Artículo 99. En los asuntos de tutela. En la revisión de acciones de tutela, el Magistrado en quien concurran causales de impedimento previstas en el Código de Procedimiento Penal deberá declararse impedido, so pena de incurrir en las sanciones penales y disciplinarias correspondientes. En dichos procesos conocerá del impedimento el resto de los Magistrados de las Salas de Selección, Revisión o Plena, según el caso. En el evento de esta disposición se observará el trámite contemplado en el artículo 27 del Decreto 2067 de 1991.

-

En el caso del artículo 137 de la Constitución, se aplicarán en lo pertinente los artículos 25 a 29 del Decreto 2067 de 1991. Podrán recusar la persona renuente y el Procurador.

-

-

[3] Auto proferido dentro de los expedientes acumulados T-7.594.854 y T-7.613.902. M.P. Diana Fajardo Rivera; Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Providencia del 21 de junio de 2018. APL2542-2018. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. En sentido similar ver Sala de Casación Civil. Providencia del 18 de agosto de 2021. ATC1196-2021. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. SV. Luis Alonso Rico Puerta.

[4] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 4 de septiembre de 1998 (MP Carlos E. Mejía Escobar). Radicado No. 14772.

[5] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 9 de mayo de 2007 (MP Jorge Luis Quintero Milanés). Radicado No. 22435. Reiterado luego, por ejemplo, en los autos del 11 de diciembre de 2007 (MP Yesid Ramírez Bastidas), radicado No. 28784; del 28 de julio de 2010 (MP Augusto J. Ibáñez Guzmán), radicado No. 34637; del 7 de junio de 2012 (MP Julio Enrique Socha Salamanca), radicado No. 39168; del 11 de febrero de 2014 (MP Fernando Alberto Castro Caballero), radicado No. 36784, entre otros. En todos estos casos, la Corte debía resolver impedimentos o recusaciones fundadas en la causal que los accionantes del presente proceso echan de menos. El Consejo de Estado, en materia de tutela en la cual se aplica el Código de Procedimiento Penal, también ha prohijado esta posición al resolver un caso similar, refiriéndose en forma expresa a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, por ejemplo, en el auto del 12 de marzo de 2015, Sección Quinta (CP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez), Expediente: 11001-03-15-000-2014-01869-01.

-

[6] Carnelutti, Francisco: *Sistema de Derecho Procesal Civil*, T. II, Uteha, Buenos Aires, 1944, pp. 270-271.